

1500122-79.2019.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: LUCIANO BRUNETTO BELTRAN

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... supostamente seria, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou.

5.1. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500122-79.2019.8.26.0322 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500122-79.2019.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2016646/2019 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 3214196 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 384/19/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2016646 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 384/19/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2016646 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 384/19/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2016646 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 384/19/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MANOEL MARCELINO DOS REIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANO BRUNETTO BELTRAN

Vistos.

1. O denunciado está sendo processado como incurso no art. 12 da Lei nº 10.826/03. Recebida a denúncia, ofertada defesa preliminar, não sendo o caso de absolvição sumária, a instrução seguiu com a produção de prova oral e o interrogatório, manifestando-se as partes em alegações finais.

A Acusação quer a procedência da ação (fls. 161/165).

A Defesa aduz que os policiais não estavam munidos de autorização judicial para o ingresso na residência, portanto, a ação foi ilegal. No mais, sustenta que não

ficou comprovada a intenção delitativa do acusado e que houve omissão na averiguação do verdadeiro proprietário da arma de fogo. Requer a absolvição, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo (fls. 177/184).

É o relatório.

DECIDO.

2. Passo à análise da prova oral.

A testemunha de acusação Márcio Costa da Silva, policial militar, na fase inquisitorial, disse que estava em serviço juntamente com o CB.PM. Carvalho. Receberam uma denúncia anônima de que Manoel possuía em sua residência uma arma de fogo e munições. Deslocaram-se até o local e foram recebidos pela mãe do autor, Maria, que franqueou a entrada. Ao perceber a presença dos militares, o réu foi até o quintal da residência e escondeu um objeto em um buraco no muro. Foi até o local e encontrou um revólver calibre 32, municiado com 06 cartuchos intactos. O réu disse que não sabia quem era o proprietário da arma de fogo. Manoel autorizou que os militares visualizassem o conteúdo de seu celular, sendo que encontraram uma conversa com Rose em que o réu enviou uma foto de arma, aparentemente a mesma apreendida. Foi dada voz de prisão em flagrante ao autor do delito (fls. 02). Em juízo, disse que os familiares do réu estavam na varanda e autorizaram a entrada dos militares na residência. Assim que Manoel visualizou a guarnição, ele se deslocou até os fundos da residência e escondeu um objeto na divisa de uma casa em construção com uma casa vizinha. Olharam o local e constaram que era uma arma de fogo. A arma estava municiada. Não conhecia o réu nos meios policiais. O réu permitiu a verificação de seu aparelho celular. Visualizaram no aparelho algumas mensagens de ameaças do réu contra uma ex-namorada, onde Manoel enviou algumas fotos de arma de fogo. A arma apreendida era semelhante à que o réu enviou as fotos. O objeto foi escondido em um vão entre dois muros, tiveram que quebrar uma parte do muro para terem acesso à arma. Viram Manoel jogando um objeto entre os muros. O réu não apresentou qualquer documentação que justificasse a posse legal dessa arma de fogo. Não lembra se Manoel informou o motivo de possuir uma arma na residência. A entrada foi franqueada por uma mulher, mas havia várias pessoas na varanda da casa. O réu estava calmo no momento da abordagem. O muro onde foi encontrada a arma não era de fácil acesso por terceiros, ficava no quintal, somente as pessoas da casa conseguiriam chegar até lá (mídia digital/SAJ).

A testemunha de acusação João Ricardo Carvalho Pereira, policial militar, na fase inquisitorial, prestou declarações no mesmo sentido da testemunha referendada anteriormente (fls. 03). Em juízo, manteve a versão, asseverando que recebeu, em companhia do capitão Márcio, uma denúncia anônima de que o réu possuía em sua residência uma arma de fogo e munição. A entrada no imóvel foi franqueada pela mãe do réu, Maria Cristina, moradora do local. Viram que Manoel correu até os fundos e escondeu algo no buraco de um muro. Nada de ilícito foi encontrado em posse do réu, mas localizaram nesse buraco do muro um revólver calibre 32, municiado com 06 cartuchos intactos. O réu não apresentou qualquer documento da arma, tampouco uma justificativa para possuir tal objeto. Não se recorda de ter verificado o celular do réu. Nunca tinha abordado o acusado. Manoel nada disse sobre a arma. Na residência estavam somente o réu e sua genitora. O buraco no tijolo do muro não atravessava para o muro do vizinho, eram dois muros, com um espaço entre eles, e o buraco estava somente do lado da casa do réu (mídia digital/SAJ).

O réu, na fase inquisitorial, disse que não sofreu agressão policial. Autorizou que os militares visualizassem o conteúdo de seu celular. Optou por manifestar-se somente na presença da autoridade judiciária (fls. 04). Em juízo, negou os fatos. Franqueou a entrada dos militares em sua residência. A casa estava em construção, estava adiantando o serviço para o pedreiro. Os policiais quebraram o muro e localizaram a arma de fogo. Não tinha conhecimento da arma. Nada tem contra os policiais. Quando era do exército, realizava treinamento junto com os militares. Os militares alegaram que havia uma denúncia e pegaram seu celular sem sua permissão. Permitiu a verificação de seu aparelho celular somente na delegacia. Possuía algumas fotos de arma no celular, mas eram baixadas da internet, como era do exército, fazia algumas "montagens" com imagens. Já respondeu por crime de trânsito. Trabalhou no exército de 2008 a 2013. Saiu da área militar pois tinha um

prazo e tentou fazer o curso, mas estava sem tempo de cuidar de suas filhas. Teve um desentendimento com sua ex-mulher por causa das filhas, mas hoje está tudo “em paz”. Conversou com a ex-mulher e ela lhe disse que não fez a denúncia. No mais, o contato que tem com ela é somente para resolver questões que envolvem sua filha. Mora com sua mãe. Trabalha com pinturas. Quando os militares chegaram a sua casa, estava no fundo da residência, medindo a construção para ver se tinha alguma coisa errada. A construção era nos fundos da residência de sua mãe. Questionado sobre uma lesão corporal contra a própria irmã, respondeu que foi tentar separar uma briga entre ela e o ex-marido dela, mas depois eles reataram o relacionamento e acabou como o “errado dessa história”. Não sabe como está a situação de tal processo (mídia digital/SAJ).

Sopesado o conjunto probatório reunido nos autos, é caso de absolvição.

De acordo com os relatos dos policiais militares, o acusado não era conhecido nos meios policiais, não havia investigação prévia sobre ele, mas na data dos fatos teriam recebido uma denúncia anônima. Isso originou a diligência à residência do réu.

Entretanto, o ingresso dos policiais militares na citada residência não restou amparada por mandado judicial ou em fundadas razões, em sintonia com entendimentos jurisprudenciais mais recentes do STJ e do STF.

Segundo teses firmadas, inclusive, com repercussão geral reconhecida – RE 603616 RO, a obediência ao devido processo legal de conhecimento penal deve observar a conhecida inviolabilidade do domicílio, com critérios seguros, ou seja, mediante autorização escrita e gravada por mecanismo audiovisual do morador, para as hipóteses em que não há mandado judicial competente.

Veja:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso – Decisão: Após o relatório e a sustentação oral, pelo amicus curiae Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, do Dr. Denis Sampaio, Defensor Público do Estado, o julgamento foi

suspenso. Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 04.11.2015. Decisão: O Tribunal, apreciando o tema 280 da repercussão geral, por maioria e nos termos do voto do Relator, negou provimento ao recurso e fixou tese nos seguintes termos: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados", vencido o Ministro Marco Aurélio quanto ao mérito e à tese. Ausentes, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, participando como palestrante do XVI Encuentro de Magistradas de los más Altos Órganos de Justicia de Iberoamerica, em Havana, Cuba, e o Ministro Roberto Barroso. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 05.11.2015" (STF, REExt 603.616/RO, Trib. Pleno, Repercussão geral mérito, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. DJe 093 10/06/2016).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que 'a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial'.

1.1 A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na companhia de seu grupo familiar, espera ter o seu espaço íntimo preservado contra devassas indiscriminadas e arbitrárias, perpetradas sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade da ressalva a tal franquia constitucional exige.

1.2. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e garantias fundamentais. Célebre, a propósito, exortação de Conde Chatham, ao dizer que: 'O homem mais pobre pode em sua cabana desafiar todas as forças da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento pode soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar, mas o Rei da Inglaterra não pode entrar!' ('The poorest man may in his cottage bid defiance to all the forces of the Crown. It may be frail, its roof may shake, the wind may blow through it, the storm may enter, the rain may enter, but the King of England cannot enter!' William Pitt, Earl of Chatham. Speech, March 1763, in Lord Brougham Historical Sketches of Statesmen in the Time of George III First Series (1845) v. 1).

2. O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência cuja urgência em sua cessação demande ação imediata é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legítima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850/2013 (art. 8º), que autorizam o retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a melhor instrumentalização da investigação e, no que interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio justificam o retardo da cessação da prática delitiva.

2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da anulação amiúde irreversível de todo o processo, em prejuízo da sociedade.

3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a tese de que: 'A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori' (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Em conclusão a seu voto, o relator salientou que a interpretação jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de sorte a trazer mais segurança tanto para os indivíduos sujeitos a tal medida invasiva quanto para os policiais, que deixariam de assumir o risco de cometer crime de invasão de domicílio ou de abuso de autoridade, principalmente quando a diligência não tiver alcançado o resultado esperado

4. As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente.

5. Se, por um lado, práticas ilícitas graves autorizam eventualmente o sacrifício de direitos fundamentais, por outro, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, excluídas do usufruto pleno de sua cidadania, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida e devassada, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes do Estado, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o local supostamente seria, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou.

5.1. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc.

5.2. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas pode fragilizar e tornar irritado o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar, a qual protege não apenas o suspeito, mas todos os moradores do local.

5.3. Tal compreensão não se traduz, obviamente, em cercear a necessária ação das forças de segurança pública no combate ao tráfico de entorpecentes, muito menos em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos ou em espaço de criminalidade. Há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso policial no domicílio alheio a situação de ocorrência de um crime cuja urgência na sua cessação desautorize o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial meio ordinário e seguro para o afastamento do direito à inviolabilidade da morada legitimar a entrada em residência ou local de abrigo.

6. Já no que toca ao consentimento do morador para o ingresso em sua residência uma das hipóteses autorizadas pela Constituição da República para o afastamento da inviolabilidade do domicílio outros países trilharam caminho judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis, geralmente limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da intimidade domiciliar e as possíveis autorizações para o ingresso alheio.

6.1. Nos Estados Unidos, por exemplo, a par da necessidade do exame da causa provável para a entrada de policiais em domicílio de suspeitos de crimes, não pode haver dúvidas sobre a voluntariedade da autorização do morador (*in dubio libertas*). O consentimento 'deve ser inequívoco, específico e conscientemente dado, não contaminado por qualquer truculência ou coerção' ('consent, to be valid, 'must be

unequivocal, specific and intelligently given, uncontaminated by any duress or coercion'). (United States v McCaleb, 552 F2d 717, 721 (6th Cir 1977), citando Simmons v Bomar, 349 F2d 365, 366 (6th Cir 1965). Além disso, ao Estado cabe o ônus de provar que o consentimento foi, de fato, livre e voluntariamente dado, isento de qualquer forma, direta ou indireta, de coação, o que é aferível pelo teste da totalidade das circunstâncias (totality of circumstances).

6.2. No direito espanhol, por sua vez, o Tribunal Supremo destaca, entre outros, os seguintes requisitos para o consentimento do morador: a) deve ser prestado por pessoa capaz, maior de idade e no exercício de seus direitos; b) deve ser consciente e livre; c) deve ser documentado; d) deve ser expresso, não servindo o silêncio como consentimento tácito. 6.3. Outrossim, a documentação comprobatória do assentimento do morador é exigida, na França, de modo expresso e mediante declaração escrita à mão do morador, conforme norma positivada no art. 76 do Código de Processo Penal; nos EUA, também é usual a necessidade de assinatura de um formulário pela pessoa que consentiu com o ingresso em seu domicílio (North Carolina v. Butler (1979) 441 U.S. 369, 373; People v. Ramirez (1997) 59 Cal.App.4th 1548, 1558; U.S. v. Castillo (9a Cir. 1989) 866 F.2d 1071, 1082), declaração que, todavia, será desconsiderada se as circunstâncias indicarem ter sido obtida de forma coercitiva ou houver dúvidas sobre a voluntariedade do consentimento (Haley v. Ohio (1947) 332 U.S. 596, 601; People v. Andersen (1980) 101 Cal.App.3d 563, 579).

6.4. Se para simplesmente algemar uma pessoa, já presa ostentando, portanto, alguma verossimilhança do fato delituoso que deu origem a sua detenção, exige-se a indicação, por escrito, da justificativa para o uso de tal medida acautelatória, seria então, no tocante ao ingresso domiciliar, 'necessário que nós estabeleçamos, desde logo, como fizemos na Súmula 11, alguma formalidade para que essa razão excepcional seja justificada por escrito, sob pena das sanções cabíveis' (voto do Min. Ricardo Lewandowski, no RE n. 603.616/TO). 6.5. Tal providência, aliás, já é determinada pelo art. 245, § 7º, do Código de Processo Penal analogicamente aplicável para busca e apreensão também sem mandado judicial ao dispor que, 'finda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4º'.

7. São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade conferir, em tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos abusivos. E, em um país conhecido por suas práticas autoritárias não apenas históricas, mas atuais, a aceitação desse comportamento compromete a necessária aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais de todos, independentemente de posição social, condição financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça.

7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação como ocorreu no caso ora em julgamento de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade.

7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado.

8. Ao Poder Judiciário, ante a lacuna da lei para melhor regulamentação do tema, cabe responder, na moldura do Direito, às situações que, trazidas por provocação do

interessado, se mostrem violadoras de direitos fundamentais do indivíduo. E, especialmente, ao Superior Tribunal de Justiça compete, na sua função judicante, buscar a melhor interpretação possível da lei federal, de sorte a não apenas responder ao pedido da parte, mas também formar precedentes que orientem o julgamento de casos futuros similares.

8.1. As decisões do Poder Judiciário mormente dos Tribunais incumbidos de interpretar, em última instância, as leis federais e a Constituição servem para dar resposta ao pedido no caso concreto e também para 'enriquecer o estoque das regras jurídicas' (Melvin Eisenberg. *The nature of the common law*. Cambridge: Harvard University Press, 1998. p. 4) e assegurar, no plano concreto, a realização dos valores, princípios e objetivos definidos na Constituição de cada país. Para tanto, não podem, em nome da maior eficiência punitiva, tolerar práticas que se divorciam do modelo civilizatório que deve orientar a construção de uma sociedade mais igualitária, fraterna, pluralista e sem preconceitos.

8.2. Como assentado em conhecido debate na Suprema Corte dos EUA sobre a admissibilidade das provas ilícitas (*Weeks v. United States*, 232 U.S. 383, 1914), se os tribunais permitem o uso de provas obtidas em buscas ilegais, tal procedimento representa uma afirmação judicial de manifesta negligência, se não um aberto desafio, às proibições da Constituição, direcionadas à proteção das pessoas contra esse tipo de ação não autorizada ('such proceeding would be to affirm by judicial decision a manifest neglect, if not an open defiance, of the prohibitions of the Constitution, intended for the protection of the people against such unauthorized action').

8.3. A situação versada neste e em inúmeros outros processos que aportam a esta Corte Superior diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas contra parcelas da população que, por sua topografia e status social e econômico, costumam ficar mais suscetíveis ao braço ostensivo e armado das forças de segurança.

9. Na espécie, não havia elementos objetivos, seguros e racionais que justificassem a invasão de domicílio do suspeito, porquanto a simples avaliação subjetiva dos policiais era insuficiente para conduzir a diligência de ingresso na residência, visto que não foi encontrado nenhum entorpecente na busca pessoa realizada em via pública.

10. A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, conseqüentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor.

11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita no caso, a apreensão, após invasão desautorizada da residência do paciente, de 109 g de maconha, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas.

12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e conseqüente absolvição do paciente, dando-se ciência do inteiro teor do acórdão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como às Defensorias Públicas dos Estados e da União, ao Procurador-Geral da República e aos Procuradores-Gerais dos Estados, aos Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que deem conhecimento do teor do julgado a todos os órgãos e agentes da segurança pública federal, estadual e distrital.

13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal" (STJ, Sexta

Turma, HC. 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, v.u., j. 02/03/2021).

Em complemento, alguns dos mais recentes entendimentos do TJSP, que adoto:

“Tráfico de drogas Ilícitude da prova obtida no momento da prisão em flagrante Garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio - Entrada em domicílio sem mandado Ausência de fundadas razões Precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça - RECURSO DA DEFESA PROVIDO” (TJSP, 12ª Câmara Criminal, Ap. 1501170-07.2020.8.26.0559, Rel. Heitor Donizete de Oliveira, j. 22/11/2021).

“Tráfico de drogas - Obtenção da prova por meios ilícitos - Policiais invadiram residência mediante arrombamento da porta - Garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio - Reconhecida a ilicitude prova obtida com invasão ao domicílio - De rigor a absolvição da ré, por ausência de materialidade - Recurso provido” (TJSP, 12ª Câmara Criminal, Ap. 1500810-89.2020.8.26.0618, Rel. Amable Lopez Soto, v.u., j. 19/11/2021).

Constou do boletim de ocorrência que a mãe do acusado, moradora do local, teria franqueado a entrada dos policiais à residência, no entanto, não há nos autos qualquer autorização expressa assinada, tampouco gravação audiovisual de alegada autorização, o que se fazia necessário, diante da ausência de mandado judicial. Portanto, imperioso concluir que, não comprovada a autorização para o ingresso na residência, realização de investigação prévia ou uma campana, a prova deve ser anulada, por se originar de um ato abusivo e, portanto, ilícito, ante a violação de garantia constitucional.

Sem que isso transpareça crítica ao trabalho dos policiais ou às declarações por eles prestadas, de acordo com o posicionamento referendado, nesses casos, simples declaração de que houve consentimento informal do morador, para cancelar tal ingresso, não é suficiente. Isso porque a inviolabilidade do domicílio se vincula ao direito à intimidade do indivíduo e de seu grupo familiar, justificando criterioso tratamento para evitar ações indiscriminadas e arbitrárias de toda ordem.

Ainda que as versões dos policiais fossem albergadas, nota-se que o consentimento do morador não foi colhido segundo os requisitos apontados, a fim de atestar com segurança, por meio de registro “cabal”, sua legalidade e voluntariedade necessárias.

Igualmente, a ação policial não pode ser compreendida como flagrante delito, pois, como se observou, o ponto de partida para a ação perpetrada se originou apenas por uma denúncia anônima, eis que ambos os policiais afirmaram que o acusado não era conhecido nos meios, e que não havia investigação prévia sobre ele ou o local dos fatos. Em sequência ao ingresso, visualizaram o acusado nos fundos da residência, mas não viram revólver em suas mãos. A arma foi encontrada em um vão entre muros. Em última análise, deve-se lembrar que o citado e recente entendimento do STJ, acerca da observância de critérios pontuais para validar a busca domiciliar e o que dela decorrer, configura respeito a valioso preceito constitucional, estampado no art. 5º, XI, da CF, que prevê:

“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Deste modo, não configurada a hipótese do flagrante delito e não havendo mandado judicial, não se pode negligenciar o aludido “consentimento”, sob pena de banalizar o que a Carta Magna cuidou de maneira explícita e direta.

É certo que, até o momento, a falta de nomas específicas gerava verdadeiro limbo sobre o assunto. Isso não é indicado nem seguro sob qualquer aspecto, principalmente na órbita criminal e em uma sociedade que proclama e tanto tem pejeado pelo respeito aos direitos fundamentais, incluindo, por certo, a inviolabilidade de domicílio.

Ademais, a falta de norte expõe diversas camadas da sociedade - senão todas, seja pela falta de critérios transparentes, para respaldar até mesmo o agir dos policiais, seja pela própria insegurança sofrida por quem fica exposto aos que se guiam segundo “suas próprias regras”.

E, como não é novidade, ao cabo dessa realidade, situa-se o próprio Poder

Judiciário, quando recebe as provas e as deve analisar, a fim de proferir decisões das quais se espera, invariavelmente, além da técnica, uma análise criteriosa, fundada em provas seguras.

A meu alvedrio, segundo o entendimento aqui adotado, os elementos probatórios nada perdem – pelo contrário – pois se está a exigir tão somente critérios claros e razoáveis – que já estão exigindo adaptações naturais salutares. Tudo a fim de se evitar alegações envolvendo ilicitudes, vícios, nulidades e excessos, conferindo-lhes, com a nova postura compreendida, a necessária segurança e credibilidade à atuação do Estado.

Logo, em harmonia com o entendimento posto, de rigor reconhecer inválidas as provas obtidas a partir do ingresso no domicílio esposado nos autos – compreendido como não autorizado, pela inobservância dos critérios definidos – e todas as demais delas decorrentes.

Reconhecida a nulidade das provas, não há de se falar que os fatos narrados na denúncia se evidenciaram.

A improcedência é, pois, de rigor.

3. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO PENAL, ABSOLVENDO-SE MANOEL MARCELINO DOS REIS das imputações contidas na denúncia, com fundamento no art. 386, II, do CPP.

Expeça-se o necessário.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Lins, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA